

0010468-48.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0010468-48.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010468-48.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO PUSCHIAVO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

LEONARDO PUSCHIAVO (RG 8951829/SP) foi denunciado como incurso no art. 12 da Lei 10.826/03, porque no dia 16 de dezembro de 2014, por volta das 13h45, na Rua Mazzini, nº 87, nesta cidade e comarca, teria em depósito um revólver, calibre.32 S&W Long, marca Rossi, e 38 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Foi instaurado inquérito policial, mediante portaria (fls. 13/14).

Foi determinada a destruição das armas e munições apreendidas (fl. 57).

A denúncia foi recebida (fl. 116). O acusado foi citado (fl. 142) e apresentou resposta à acusação (fl. 146). Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 148).

Durante a instrução foi ouvida a testemunha policial e, ao final, houve o interrogatório.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia, com a consideração da sua condenação posterior como conduta social negativa.

A Defesa requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II ou VII do

Código de Processo Penal, e subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo, a substituição da pena por restritiva de direito, a fixação de regime aberto e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A testemunha policial Edvaldo Moises Amorim declarou, extrajudicialmente, que, junto com o seu colega, foi atender a uma ocorrência de desinteligência entre o acusado e a sua esposa (Rose Clel de Oliveira). Afirmou que, segundo constava, Rose já havia efetuado um boletim de ocorrência na DDM, sendo que na data dos fatos, após um novo desentendimento entre o casal, os policiais militares foram acionados, sendo que o acusado acabou se evadindo antes da chegada dos mesmos. Declarou que Rose indicou aos policiais que havia duas armas em um armário na residência, pertencentes ao seu marido, Leonardo, que realmente foram localizadas pelos policiais, uma espingarda de pressão e um revólver, bem como uma quantidade de munições.

Em juízo, a testemunha afirmou que nesse endereço havia um envolvimento de arma, não lembra se era briga de marido e mulher, e chegando no local, parece que familiares do réu indicaram que ele havia se desentendido com alguém de lá, mas ele não estava mais lá, e indicaram que havia uma arma e munições no local, e foi mostrada essa arma e essas munições, e conduziram até o distrito para apreensões. Disse que não lembra ao certo qual era o teor do chamado, mas o réu não estava no local, e também não lembra onde estavam as armas, se foi localizado por um policial, já que não era o único agente no local, haviam vários, ou se foi informado pelo próprio proprietário o local exato. Informou que era o condutor da ocorrência, e quando são localizados os objetos, levam até ele. Repetiu que não se lembra do local onde foi localizada a arma. Informou que lá moravam os familiares e se não se engana teve contato com 2 mulheres, pois faz muito tempo. Disse que entregaram a arma para ele e ele conduziu ao distrito, acha que um dos familiares indicou para a polícia. Asseverou que não lembra como foi a dinâmica da localização, se alguém indicou onde estava a arma.

O acusado, em sede policial, afirmou que estava ciente da presente ocorrência, versando sobre um revólver calibre .32 e uma espingarda de pressão. Declarou que as armas pertenciam ao seu pai, Roberto Puschiavo, aposentado da Polícia Militar, falecido no ano de 2002. Afirmou que, após o falecimento de seu genitor, manteve em sua posse os seus pertences, entre eles as armas. Disse que a espingarda não funcionava há muito tempo e que o revólver estava guardado dentro de uma caixa sobre o guarda roupa e também havia diversas munições velhas do tempo de seu genitor. Sustentou que nunca comprou munição ou fez uso da arma. Por fim, aduziu que as armas foram entregues na delegacia através de seu filho, logo após o declarante ter separado de sua esposa e que nunca fez uso da arma ou ameaçou a sua esposa com ela.

Em juízo, o acusado negou a acusação. Narrou que teve um processo de separação da sua então esposa, Rose Clel de Oliveria, com quem teve uma discussão feia, e ela saiu de casa, ficou uma semana fora, enquanto ele ficou com as crianças, então ela fez um B.O., com um pedido de medida protetiva, em razão da discussão, e ele teve que sair de casa, enquanto ela retornou. Explicou que depois do dia que ela saiu, ele nunca mais a viu, ele não foi mais ao apartamento, pois ela não deixava mais ele entrar, e ele nunca mais apareceu por lá, ou seja, nunca mais se viram. Quanto às armas, relatou que seu pai foi da antiga polícia marítima e aérea, depois passou para a polícia militar e foi sub reformado como subtenente, e essa espingardinha de chumbo e o revólver eram dele. Informou que em um certo momento da vida, ele ficou viúvo, teve duas isquemias, problemas de saúde, ficou um tempo na sua casa, e trouxe essas armas para a casa. Alegou que nunca manuseou essas armas, que a Rose, então esposa, guardou com medo que as crianças mexessem. Em relação às munições, asseverou que tinha muitas munições, mas não era da arma, eram munições antigas que o seu pai teve ao longo da vida de polícia, e o seu pai deixava guardadas numa gaveta com diversos tipos de calibres, mas não eram das armas, e acha que o revólver .32 não tinha bala nenhuma. Repetiu que nunca manuseou, nunca mexeu, que foi sua esposa quem guardou. Informou que depois que saiu da sua casa, pegou os seus pertences pessoais, uma televisão, um computador e um violão, nunca mais

voltou lá. Disse que para ele essa arma estava esquecida, e só foi lembrar quando parou uma viatura da polícia civil na frente da sua casa, com um BO, pedindo para que ele comparecesse na delegacia, e foi avisado, na DP, que sua esposa tinha ligado para a polícia e entregou a arma, então explicou essa história de que as armas eram do seu pai. Aduziu que a arma fosse sua, teria levado embora, mas mal sabia onde estava, e se alguém manuseou, foi ela, que pegou para entregar à polícia, mas quer acreditar que ela não queria o prejudicar, que ela queria preservar as crianças e estava com medo de ter uma arma dentro de casa com 3 filhos lá dentro. Falou que acredita que ela fez errado, pois depois de consultar um amigo soube que ela deveria ter feito um documento para poder transportar essa arma até a delegacia, pois se você pegar a arma e é pego no meio do caminho pode ocorrer algum problema. Disse que realmente não estava na casa quando o policial foi lá, porque já tinha saído de casa. Falou que nunca manuseou uma arma, nunca ameaçou alguém com uma arma, e nem tinha porquê. Informou que seu pai faleceu em 2002 e o próprio pai levou a arma para a sua casa antes de morrer. Disse que seu pai, como policial, sempre andava armado, e antes de morrer, já com problemas de saúde, ele foi até a casa do réu e pediu para deixar as arma lá, então tirou todas as munições, entregou na mão da sua então esposa, e ela guardou não sabe onde e para ele, nem existia mais essas armas e munições. Respondeu que foi processado e condenado, salvo engano, há 17 ou 30 dias em prisão domiciliar, só sabe que tinha que ficar 17 dias em casa sem poder sair, sem poder fazer nada, só trabalhar. Informou que foi casado por 22 anos e saiu de casa depois desses fatos, dessa discussão, da Maria da Penha. Falou que nunca mais entrou no apartamento onde ela mora com os dois filhos gêmeos caçulas, pois uma filha casou. Informado pelo Promotor de Justiça de que, na delegacia, a ex-esposa informou que não sabia das armas, que não eram delas, falou que realmente não eram dela, eram do seu pai. Disse que não sabe as datas exatas, mas confirmou que saiu de casa em data anterior a 16/12/2014, saiu quando a Justiça determinou, e só ficou sabendo a respeito da apreensão das armas quando o policial civil foi até a sua casa e pediu para ele comparecer na delegacia para um depoimento, e lá ficou sabendo que essas armas tinham sido devolvidas à polícia pela sua ex-esposa, e foi então que se lembrou desse armamento, pois nem se lembrava mais. Informou que isso ocorreu em 2014 ou 2015, e o policial veio à sua casa só em 2017.

Pelo que se depreende dos autos, a polícia militar teria comparecido ao local dos fatos em razão de um desentendimento ocorrido entre um casal e, lá chegando, o marido, ora réu, não se encontrava no local, enquanto a esposa teria permitido a entrada dos policiais na residência, os quais encontraram a arma e as munições, cuja existência ela própria não teria conhecimento.

O réu informou que na data dos fatos já não estava morando naquela casa. Alegou que teria saído do lar por determinação judicial, já que sua então esposa teria solicitado medida protetiva de urgência. Afirmou que as armas e munições localizadas pertenceram a seu pai, falecido em 2002, e que o próprio genitor as levou até lá. Aduziu que já nem lembrava desse armamento.

Sem avançar muito no mérito, verifica-se que não há provas sobre a autoria. De fato, conforme se constata pelos antecedentes criminais, o réu foi processado por crimes relacionados à violência doméstica e teve medida protetiva imposta contra si em data anterior aos fatos. Além disso, o próprio policial informou que o réu não se encontrava no local quando atendeu a ocorrência.

Ademais, o agente da polícia ouvido em juízo não se lembrou como ocorreu a apreensão das armas e munição, e a então esposa do réu não foi arrolada para também ser ouvida em juízo e esclarecer como se deu a dinâmica dos fatos.

No mesmo sentido, não há comprovação se houve autorização para que os policiais adentrassem ao domicílio e fizessem a busca para localizarem as armas e munições. Segundo o boletim de ocorrência (fls. 15/16), os policiais teriam sido acionados para atenderem uma ocorrência de desinteligência entre o casal, ocasião em que a esposa teria indicado aos policiais que haviam duas armas dentro da residência. Ouvida na delegacia (fl. 30), ela informou que não sabia de qualquer arma e autorizou a entrada dos policiais, a pedido destes. Ela não veio a juízo para confirmar sua versão. Não há prova, portanto, do consentimento do morador do

domicílio para que fosse realizada a busca.

O ingresso dos policiais no imóvel sem autorização judicial ou sem a prova do consentimento do morador, torna ilegal tudo que foi encontrado e, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, são nulas todas as provas derivadas do encontro da arma e das munições, não sobrando, portanto, mais nada que incrimine o réu.

Nesse sentido, já decidiu o referido Tribunal:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 8. Vale anotar que a Sexta Turma estabeleceu o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além da anulação das provas colhidas nas investigações. 9. Fixou, ainda, as seguintes diretrizes para o ingresso regular e válido no domicílio alheio, que transcrevo a seguir:

"1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser

classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. 3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência."

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, na AP n. 132/2.20.0001682-3. Expeçam-se, também, alvará de soltura em benefício do paciente e, nos termos do art. 580 do CPP, da corrê.

(STJ. HC: 616.584 – RS. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Julgado no dia 30 de março de 2021) (Grifo nosso)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige. 1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1). 2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de

tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação – e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio – justificam o retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação – amiúde irreversível – de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado. 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. 5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. 5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos – diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local. 5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial – meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada – legitimar a entrada em residência ou local de abrigo. 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência – uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio – outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. 6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável

para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (*in dubio libertas*). O consentimento “deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção (“*consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'*”). (United States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977)), citando Simmons v Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (*totality of circumstances*). 6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. 6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579. 6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa – ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção –, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, “necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis” (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal – analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial – ao dispor que, “[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º”. 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas atuais –, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. 8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor

regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares. 8.1. As decisões do Poder Judiciário – mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição – servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para “enriquecer o estoque das regras jurídicas” (Melvin Eisenberg. *The nature of the common law*. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos. 8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (Weeks v. United States, 232 U.S. 383, 1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada (“such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action”). 8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital. 13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. (STJ. HC: ° 598.051 – SP. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado no dia 02 de março de 2021.)



Portanto, de rigor, o reconhecimento da ilicitude da prova localizada dentro do imóvel, já que obtida por meio de invasão de domicílio, e da não comprovação da apreensão de arma e munições na posse do réu, com a sua consequente absolvição por ausência da materialidade do crime de depósito de arma e munições.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, por consequência, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu LEONARDO PUSCHIAVO (RG 8951829/SP) da imputação de ter infringido o disposto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03.

Considerando que não mais interessam à persecução penal, autorizo a restituição das armas apreendidas, desde que comprovada adequadamente esta condição e devidamente regularizadas. Comunique-se à autoridade policial, consignando-se que as armas não reclamadas, no prazo de 10 (dez) dias, deverão ser destruídas, nos termos do art. 509, § 3º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA